

1531577-82.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... visto o adolescente. Wesley negou o tráfico, dizendo que o menor estava vendendo. O outro também disse que era o menor que estava vendendo. Os outros dois estava sentado um pouco mais afastado das drogas; Wesley estava sentado ao lado das drogas. Não aparentavam ter feito uso de droga. Interrogado, WESLEY LIRA DE OLIVEIRA confessou o tráfico. Afirmou estava junto com Gabriel ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531577-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531577-82.2021.8.26.0228 PD 12/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10 de fevereiro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presentes os réus Dheroty dos Santos Oliveira e Wesley Lira de Oliveira, acompanhados pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição dos acusados. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado os interrogatórios dos réus nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado

encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, os réus DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA e WESLEY LIRA DE OLIVEIRA foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos artigo de 33, caput e artigo 35 c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, todos os crimes c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal. Isso porque, consta da inicial acusatória que, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 10h30min, em plena vigência de calamidade pública, decretada por ocasião da Pandemia do COVID-19, na Ermenegildo Martini, 52, - Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca, em via pública, agindo em concurso de agentes com o adolescente Gabriel De Sousa Santana, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e transportavam, com fins de comercialização, 30 porções contendo substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, com peso de 31 gramas, 40 porções contendo substância entorpecente denominada "Cocaína" em material sólido petrificado, vulgarmente conhecida como "Crack", com peso de 7,5 gramas, e 4 frascos contendo substância entorpecente denominada "Cloreto de Metileno/diclorometano", vulgarmente conhecida como "Lança-perfume", com peso de 80 mililitros, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 33, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls. 35/38 e laudo de exame químico toxicológico que será oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA e WESLEY LIRA DE OLIVEIRA, já qualificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não o crime de tráfico de entorpecentes. Devidamente notificados, os réus ofereceram defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regularmente recebida. Os réus foram devidamente citados. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo os réus interrogados no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 05/08, auto de exibição e apreensão de fls. 33, bem como pelo laudo de constatação de fls. 35/38 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls.207/209, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder dos réus, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogados, os réus negaram a acusação (fls.17 e 25). Em juízo, o réu WESLEY afirmou que estava na venda com o menor Gabriel e que Derothy foi lá para comprar a droga. O réu DEROOTHY, por sua vez, corroborou o depoimento do corréu Wesley dizendo que foi lá tão somente para comprar a droga. A negativa dos fatos pelos réus não convence e restou isolada das demais provas. Vejamos. Ouvidos na fase inquisitiva os policiais afirmaram que faziam o patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas e, ao adentrarem uma viela que dava acesso a biqueira, localizaram os denunciados DHEROTY e WESLEY, juntamente com o adolescente Gabriel, sentados ao chão. Ao avistar a chegada da polícia militar, WESLEY, que estava com uma sacola plástica em seu colo, correu em direção ao portão da viela na tentativa de fugir, mas sem conseguir abri-lo, retornou ao local que estava e deitou-se ao chão, obedecendo ao comando dos militares. Em revista pessoal, encontraram com WESLEY, dentro da sacola plástica que trazia consigo, 30 porções de maconha, 40 porções de crack e 4 frascos de laça perfume, bem como a quantia de R\$10,00 (dez reais). Questionados, os denunciados DHEROTY, WESLEY e o adolescente Gabriel disseram que estavam no local apenas para comprar drogas, sendo que se sentaram no chão para esperar o traficante chegar. WESLEY alega que a sacola com drogas estava no chão. Em juízo, os policiais confirmaram a versão acima. A policial Ane confirmou que os réus estavam sentados no chão, todos os 3 (incluído o

menor) no ponto de venda de drogas. Wesley tentou fugir porém foi dada voz de prisão e, com ele estava a sacola, que continha pedras de crack, maconha e não lembra se tinha cocaína, porções prontas para a venda. Indagados, eles negaram. Um deles estava com as drogas na mão (Wesley). Confirmada a quantidade de drogas descritas na denúncia, confirmou. O policial Jean também confirmou a versão da fase policial. É certo que a genitora do adolescente Gabriel foi ouvida em solo policial e relatou que seu filho é amigos dos dois envolvidos e que eles já praticaram outros crimes, inclusive tem ciência de que Gabriel já vendeu drogas em outras circunstâncias. A expressiva quantidade e variedade de estupefacientes, forma de acondicionamento e demais circunstâncias da prisão indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Apurou-se que os denunciados estavam conluiados para a prática do delito, tanto que foram presos em flagrante, em um ponto de venda de drogas. Ademais, restou verificado que a prática delitiva envolveu participação do adolescente Gabriel, cuja genitora confirmou o envolvimento de seu filho na prática de crimes juntamente com os dois denunciados, de quem é amigo. Saliento que o crime foi cometido durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020 (decretos de calamidade pública), em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Desta forma, o depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso... A bem da verdade os que sustentam o teratológico “recebimento com ressalvas” do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: “O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos” (TJSP – AC 205162-3/4 – Rel. Jarbas Mazzoni – RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação incumbiu-se de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP, além dos péssimos antecedentes. Já na

segunda fase, observo a agravante da calamidade pública do art. 61, II, "j" do CP para ambos e da REINCIDÊNCIA para o réu DHEROTY (FLS. 194). Finalmente, na terceira e derradeira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" – seja na sua forma tentada ou consumada –, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que os acusados sejam CONDENADOS nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dada a palavra à Dr(a). Defensora dos réus, assim se manifestou: "MM. Juiz, WESLEY LIRA DE OLIVEIRA E DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA, já qualificados nos autos da ação penal em epígrafe, vêm, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. Os réus foram denunciados como incurso no Art. 33, caput, art. 35 c.c art. 40, Inciso VI da Lei nº 11.343/06 c.c art. 69 e art. 61, Inciso II, alínea "j" do CP, pelos fatos descritos na denúncia. Os acusados foram notificados, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridos dois

policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e os acusados foram interrogados ao final. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação nos termos da denúncia. Contudo, em que pese a manifestação ministerial, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. A PM ANE KAROLINE ALBUQUERQUE DINIZ declarou em juízo que o local é de conhecimento por ser biqueira e ao entrarem na viela encontraram os três (Wesley, Dheroty e Gabriel), que tentaram fugir, mas não conseguiram. A droga apreendida estava em uma sacola (crack, maconha e não se lembra se tinha cocaína) em porções prontas para venda. Os réus negaram. Um deles estavam com as drogas nas mãos. É de costume do lugar. Foi a primeira vez que os abordou. Confirmou a pergunta da d. Promotora que Wesley estava com a sacola no chão e tentou correr. Havia R\$10,00 em dinheiro trocado. Cada um falou uma coisa; um falou que estava de passagem, outro que estava no local para consumo. O dinheiro estava na sacola. Os três estavam sentados próximos. Não percebeu sinal de uso de maconha em nenhum deles. O PM JEAN CARLOS DOS SANTOS NOBRE foram patrulhar em local onde sabe que é ponto de venda de droga. Abordou uma pessoa, que não tinha nada a ver com o tráfico. Esse local dava acesso a uma viela; avistou Wesley com sacola de droga no colo. Tentaram correr, mas sua parceira estava do outro lado do portão. Foi dada voz de prisão. Acredita que os três abordados estavam na venda de drogas. Á tinha visto Wesley no local antes; não havia visto o adolescente. Wesley negou o tráfico, dizendo que o menor estava vendendo. O outro também disse que era o menor que estava vendendo. Os outros dois estava sentado um pouco mais afastado das drogas; Wesley estava sentado ao lado das drogas. Não aparentavam ter feito uso de droga. Interrogado, WESLEY LIRA DE OLIVEIRA confessou o tráfico. Afirmou estava junto com Gabriel e depois chegou Dheroty pedindo para comprar maconha, mas não tinha troco. Logo depois chegaram os policiais e abordaram os três. Estava na venda junto com Gabriel. Dheroty só foi comprar droga. Está arrependido. Em seu interrogatório, DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA negou o tráfico. Foi a biqueira comprar droga, é usuário. Não tinha troco inteiro e ficou esperando quando a polícia fez a operação e levou os três. Wesley estava na venda com Gabriel. Foi levado junto. A polícia "se apegou mais" porque já tinha passagem. Apesar da confissão do acusado WESLEY com relação ao tráfico de drogas, percebe-se que se trata de um caso no qual repousam sérias dúvidas acerca da configuração delitiva. Não há provas cabais de autoria delitiva, pois a confissão não é rainha das provas e é necessário analisá-la em conjunto com as demais provas dos autos. No presente feito, de fato, não há qualquer prova concreta do crime de associação, já que inexistente notícia de estabilidade ou permanência. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento CONSOLIDADO nesse sentido (STJ - HC: 108359 MS 2008/0127780-5). O mero fato de existir mais de um réu não ultrapassou o simples concurso de agentes, que, a toda evidência, não poderia ter acontecido. Ademais, as provas dos autos apontaram tão somente para apreensão de entorpecentes com um corréu WESLEY. Para tal aplicação, deve haver inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os agentes tenha sido assentada com essa precisa finalidade de constituir sociedade espúria para a comercialização de entorpecentes, o que não ocorreu no presente feito. Não houve, portanto, investigação prévia. Sequer campanha foi realizada, de acordo com o depoimento dos policiais. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada, que deve ser interpretada em favor dos réus, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Desse modo, requer-se a ABSOLVIÇÃO dos acusados nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal de todos os delitos a eles imputados. Subsidiariamente, com relação ao corréu DHEROTY requer-se a desclassificação para o art. 28, caput da Lei de Drogas, com aplicação somente de pena de advertência. Em caso de eventual condenação pelos delitos imputados na denúncia, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 Código penal e 42 da Lei nº 11.343/06, ressaltando-se que WESLEY é primário e de bons antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, requer-se o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão com relação a WESLEY, superando o entendimento da Súmula 231 do STJ em razão do princípio da individualização da pena. Da mesma forma, no

tocante ao acusado DHEROTY requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ. A agravante da calamidade pública deve restar afastada. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que WESLEY é primário, tem bons antecedentes e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. A mesma sorte assiste a DHEROTY, pois, caso reconhecida reincidência, na terceira fase, como medida de proporcionalidade, evitando-se o abominável bis in idem, deve-se reconhecer o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. A causa de diminuição em apreço não pode ser afastada em razão de reincidência eventualmente reconhecida na segunda fase da dosimetria penal, por refletir inegável bis in idem, pois a mesma circunstância está sendo valorada em dois momentos distintos. Ademais, a reincidência não é específica. Na terceira fase, se reconhecida participação do adolescente GABRIEL no tráfico, requer-se a aplicação da causa de aumento no mínimo legal. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade. Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WESLEY LIRA DE OLIVEIRA e DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo de 33, "caput" e artigo 35 c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, todos os crimes c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 10h30min, em plena vigência de calamidade pública, decretada por ocasião da Pandemia do COVID-19, na Rua Ermenegildo Martini, 52, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, em via pública, em concurso de agentes e juntamente com o adolescente Gabriel De Sousa Santana, guardavam e transportavam, com fins de comercialização, 30 porções contendo substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como Maconha, com peso de 31 gramas, 40 porções contendo substância entorpecente denominada "Cocaína" em material sólido petrificado, vulgarmente conhecida como "Crack", com peso de 7,5 gramas, e 04 frascos contendo substância entorpecente denominada "Cloroformo de Metileno/diclorometano", vulgarmente conhecida como "Lança-perfume", com peso de 80 mililitros, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 33, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls. 35/38 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 207/209, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que os acusados estavam previamente associados para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Os réus foram presos em flagrante delito e permaneceram custodiados no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 143/145), os réus foram citados (fls. 200 e 202), sendo apresentada resposta à acusação no termo de audiência. Durante a instrução criminal foram ouvidos os Policiais Militares responsáveis pela prisão dos acusados e apreensão do menor infrator. Os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público requereu a condenação. A Defesa postulou a absolvição. Subsidiariamente, quanto ao réu Wesley, pediu a responsabilização pelo tráfico privilegiado, diante do teor da confissão judicial. Quanto ao co-réu Dheroty, pediu a responsabilização por porte de droga, na medida em que o acusado alegou ter se dirigido ao local, na condição de usuário comprador, sendo que eram Wesley e o menor Gabriel aqueles que procediam a venda das substâncias. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Impõe-se a condenação de Wesley pelo delito de tráfico de drogas privilegiado e a condenação de Dheroty por porte de drogas. Vejamos. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 02/06; pelo A.E.A. de fls. 33; pelo laudo de constatação de fls. 35/38; e pelo L.E.Q.T. de fls. 207/209. Os PMS,

ouvidos nas duas fases procedimentais, disseram que o local já era de prévio conhecimento policial, por se tratar de ponto de venda de drogas. Eis que ingressaram pela viela que dava acesso à “biqueira” e ali se depararam com o réu Wesley, sentado, na posse de uma sacola plástica, no interior da qual localizaram as porções de droga e R\$ 10,00. Próximo de Wesley estavam o menor Gabriel e ainda o co-réu Dheroty. Os três foram abordados e conduzidos ao Distrito Policial, onde foi lavrado flagrante de tráfico de drogas, com relação a Wesley e Dheroty. Eis que em Juízo, ao ser interrogado, o réu Wesley confessou expressamente que fazia a venda de drogas na referida “biqueira”, juntamente com o menor Gabriel, sendo que Dheroty foi até o local na condição de usuário comprador, para adquirir drogas para uso pessoal. Enquanto Dheroty aguardava o troco, para deixar a “biqueira”, surgiram os PMS que vieram a deter os três. Por sua vez, o réu Dheroty, interrogado em Juízo, reiterou o mesmo contexto externado por Wesley. Disse que é usuário de drogas e foi até a “biqueira” para comprar entorpecentes para seu uso pessoal. Ali foi atendido por Wesley e Gabriel, responsáveis pela venda das porções, sendo que enquanto aguardava o troco, veio a ser preso juntamente com os traficantes, pela Polícia Militar. Certo é, diante do conjunto probante, que Wesley era quem estava na posse direta das drogas, tal qual referido pelos PMS e confessado pelo próprio acusado. Wesley inclusive admitiu espontaneamente em Juízo, ao ser interrogado, que realmente fazia a venda das substâncias consigo encontradas, sendo auxiliar pelo menor Gabriel no ilícito comércio. Os PMS, nos seus depoimentos, não descreveram quaisquer ações efetivas, por parte de Dheroty, no sentido do mesmo estar participando da venda de drogas, promovida por Wesley e Gabriel. Dheroty, tal qual consignado acima, deu a versão de que estava pelo local, apenas para comprar drogas para seu uso pessoal, negando participação no tráfico, de responsabilidade de Wesley e Gabriel. Assim, os elementos de prova impõem a responsabilização de Dheroty como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, na medida em que não ficou demonstrada sua concorrência criminosa na venda dos entorpecentes. Quanto ao réu Wesley, temos que era quem estava com as drogas, tendo o mesmo assumido que realmente fazia a venda das porções, juntamente com o menor Gabriel, sendo mister sua condenação pelo delito de tráfico, com a causa de aumento referente ao envolvimento do menor. Outrossim, não há prova suficiente de que os acusados estivessem previamente associados, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas, impondo-se a absolvição quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas. Assim delimitada a responsabilidade de cada um dos acusados, passo à dosagem das penas. No tocante a imposição de pena do réu Dheroty, ora responsabilizado apenas pelo porte de drogas, caberá apenas a medida de advertência para que não torne a delinquir. Quanto ao réu Wesley, flagrado na posse direta das drogas, o qual inclusive assumiu em Juízo que fazia a venda das porções, juntamente com o menor Gabriel, fixo a pena-base no mínimo legal, diante da primariedade técnica, o que perfaz 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A agravante da calamidade pública fica compensada com a atenuante da confissão. Considerando que o réu Wesley traficava na companhia do adolescente Gabriel (art. 40, VI, Lei 11.343/06), aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por não ter ficado comprovado que o réu Wesley integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para: a) CONDENAR o réu WESLEY LIRA DE OLIVEIRA, RG/SP 38.349.743-7, ao cumprimento de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06; b) DESCLASSIFICAR a imputação originária capitulada no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e CONDENAR o réu DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA, RG/SP 55.144.491-5 e CPF 480.008.868-20, como incurso no artigo 28, inciso III, da Lei nº

11.343/06, servindo o tempo de custódia cautelar, como medida de advertência para que o sentenciado não torne a delinquir e se envolver com entorpecentes; e c) ABSOLVER os réus WESLEY LIRA DE OLIVEIRA e DHEROTY DOS SANTOS OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, da imputação referente ao delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao sentenciado Wesley, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu Wesley por pena restritiva de direito consistente na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado Wesley deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Ainda quanto ao sentenciado Wesley, uma vez beneficiado com a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, determino a expedição de alvará de soltura clausulado. O sentenciado Wesley sai intimado a fazer o recolhimento do valor de R\$ 7.113,33, correspondente à pena de multa, no prazo de quinze dias. No tocante ao sentenciado Dheroty, responsabilizado como incurso no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, consigno que por conta da natureza da pena de advertência aplicada, dada por cumprida nesta data, deve ser expedido alvará de soltura clausulado. O valor em dinheiro arrecadado deverá ser revertido em favor da SENAD. Providencie-se a incineração das drogas. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu Dheroty:

Réu Wesley:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA